

0004987-32.2015.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... a praticarem os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. (fls. 3/4).

A denúncia foi recebida em 09.04.2015 (fls. 137/138).

Regularmente notificado (fls. 280/282), o denunciado apresentou defesa prévia, por intermédio de defensor nomeado, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 306/310).

Foi revogada a prisão preventiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004987-32.2015.8.26.0268 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004987-32.2015.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 013/2015 - 1º Distrito Policial de Itapecerica da Serra, 83/2015 - 1º Distrito Policial de Itapecerica da Serra

Réu:

GUILHERME DOS REIS BATISTA

Juiz de Direito Substituto: Dr. LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra GUILHERME DOS REIS BATISTA (fls. 3/7), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do arts. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29 do Código Penal; art. 35 da Lei nº 11.343/2006; e art. 244-B, caput, do ECA, todos na forma do art. 69 do Código Penal, pela suposta prática dos seguintes fatos delituosos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de janeiro de 2.015, por volta das 18h, na Rua São Pedro, altura do nº 03, Jardim do Carmo, nesta cidade e Comarca de Itapecerica da Serra, os adolescentes Michael de Moraes Carloto e Bruno Santos Silva guardavam 168 (cento e sessenta e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 78g (setenta e oito gramas), para entrega ou consumo de terceiros, nas proximidades da Escola Estadual Jardim do Carmo, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão acostado a fls. 13/14 e laudo de constatação provisória acostado a fls. 15/16.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, JORGE MAGNO RIBEIRO DO NASCIMENTO, vulgo "Neguinho", qualificado a fls. 65, e GUILHERME DOS REIS BATISTA, vulgo "Gui", qualificado indiretamente a fls. 73,

agindo em concurso e com unidade de desígnios entre eles, concorreram, de qualquer modo, para o crime de tráfico de drogas acima descrito.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, JORGE MAGNO RIBEIRO DO NASCIMENTO, vulgo "Neguinho", qualificado a fls. 65, e GUILHERME DOS REIS BATISTA, vulgo "Gui", qualificado indiretamente a fls. 73, associaram-se entre si e com os adolescentes Michael de Moraes Carloto e Bruno Santos Silva, para o fim de praticarem, de forma reiterada, o crime de tráfico de drogas.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, JORGE MAGNO RIBEIRO DO NASCIMENTO, vulgo "Neguinho", qualificado a fls. 65, e GUILHERME DOS REIS BATISTA, vulgo "Gui", qualificado indiretamente a fls. 73, corromperam menores de dezoito anos, quais sejam, os adolescentes Michael de Moraes Carloto e Bruno Santos Silva, com eles praticando ou induzindo-os a praticarem os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. (fls. 3/4).

A denúncia foi recebida em 09.04.2015 (fls. 137/138).

Regularmente notificado (fls. 280/282), o denunciado apresentou defesa prévia, por intermédio de defensor nomeado, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 306/310).

Foi revogada a prisão preventiva do réu, concedendo-se a liberdade provisória, cumulada com medidas alternativas (fls. 407/408).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para os dias 30.11.2021 e 23.02.2022 (fls. 314/315, 317/319, 421/424 e 475/477).

Nas datas aprazadas, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais oralmente (termos de audiência de fls. 466/467 e 515/516 e respectivas mídias audiovisuais).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva improcede.

O sistema penal assenta-se na presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), de tal sorte que "a sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à realidade" (Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha, Da prova no Processo Penal, 1994, p. 64). Nos dizeres de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, referida certeza consiste na "conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33) que a 'íntima convicção', como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples crença" (Jurisprudência Criminal, Forense, 1982, nº 446).

No âmbito processual penal, a presunção de inocência tem ressonância no princípio do in dubio pro reo, o qual impõe ao órgão acusador o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e a efetiva responsabilidade criminal do réu (art. 156 do CPP).

A materialidade delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência nºs 83/2015 e 11/2015 (fls. 10/14 e 15/19, respectivamente), no auto de exibição e apreensão (fls. 20/21) e nos laudos de constatação preliminar (fls. 22/23) e definitivo de exame químico-toxicológico das substâncias apreendidas (fls. 114/115). Depreende-se de tais elementos cognitivos que foram apreendidas na viela localizada na Rua São Pedro, altura do nº 03, Jardim do Carmo, em poder dos adolescentes Michael Moraes Carloto e Bruno Santos Silva, 168 porções de cocaína, com peso líquido de 78 gramas. O exame químico-toxicológico atesta que as substâncias entorpecentes são causadoras de dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da

Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Em contrapartida, a despeito de os indícios amealhados na fase pré-processual apontarem o acusado como o possível coautor ou partícipe dos crimes que lhe são imputados, não foram coligidas, em juízo, provas suficientes de autoria. Com efeito, o policial civil Leonardo Pereira Alves, ouvido na condição de testemunha em ambas as fases da persecução penal, relatou que: receberam denúncia anônima de que, no endereço supra, numa viela, havia dois indivíduos, aparentemente menores, comercializando drogas; o denunciante relatou que o “gerente” seria a pessoa de alcunha “Magno”, que estaria próxima dos indivíduos; diligenciaram ao local dos fatos e efetuaram cerco na viela, em que existe um “escadão”, tendo observado, de imediato, os indivíduos com as características físicas e vestimentas descritas pelo denunciante sentados na entrada da viela; em revista pessoal, foram encontrados com o adolescente Bruno R\$ 200,00 em dinheiro trocado; próximo a eles, no interior da viela, lograram apreender os entorpecentes prontos e embalados para a venda; informalmente, Michael admitiu que estava trabalhando para o tráfico, como “olheiro”, e que Bruno era o responsável pela venda; na unidade policial, Michael reconheceu fotograficamente o acusado como um dos responsáveis pelo comércio de drogas na localidade. Indagada por este Julgador, a testemunha respondeu que se tratou de uma denúncia de que na viela havia dois menores traficando drogas, mas que não havia investigação prévia em torno de eventual associação para a mercancia ilícita. Confrontado pelo douto Defensor, o testigo redarguiu que: da denúncia anônima não constava o nome do “Guilherme”, mas apenas dos dois adolescentes e de Magno; o nome do acusado surgiu depois, figurando como um dos pretensos patrões, a partir de um reconhecimento fotográfico, de forma completamente aleatória; nunca viu Guilherme pessoalmente nem teve contato com ela, apenas o visualizou na foto àquela época (fls. 26/27 e mídia audiovisual da primeira audiência).

O policial civil Geraldo Ribeiro dos Santos reproduziu, essencialmente, a narrativa de seu colega Leonardo, enaltecendo que um dos adolescentes reconheceu fotograficamente o réu como sendo o “gerente” do tráfico ilícito de drogas operado na localidade, situado acima de “Magno” na hierarquia da mercancia ilícita. Disse que não teve operação anterior para apurar a estabilidade e a permanência da suposta associação para o tráfico e que a participação do acusado na perpetração dos crimes defluiu tão somente da palavra dos adolescentes. Em resposta às perguntas formuladas pelo douto Patrono, afirmou que os entorpecentes foram encontrados com os adolescentes, bem assim que tomou parte na diligência que culminou com a prisão do Magno, não tendo este, em nenhum momento, citado a participação de Guilherme na empreitada delitiva. Reiterou que o único reconhecimento do acusado se deu por foto (termo de fls. 24/25 e mídia audiovisual da primeira audiência).

Na Delegacia de Polícia, o adolescente Michael de Moraes Carloto reconheceu fotograficamente o acusado como sendo um dos supostos gerentes do tráfico de entorpecentes do bairro Jardim do Carmo (termo de declaração de fls. 32/33 e auto de reconhecimento de fl. 36). O adolescente Bruno Santos Silva, por sua vez, asseverou nunca ter visto Guilherme (fl. 33). Os menores não depuseram em juízo, porque as partes desistiram das suas oitivas.

Na senda judicial, o réu negou a prática delitiva. Alegou, em suma, que não tem envolvimento nenhum com o tráfico de drogas, e que o policial Geraldo teria lhe exigido o pagamento de R\$ 5.000,00 para que fosse liberado da ocorrência. Uma vez que não acedeu à exigência indevida do agente policial, este passou a persegui-lo injustamente (mídia audiovisual da segunda audiência).

Como se vê, não obstante as provas colhidas no curso da instrução assentem um juízo de certeza acerca da prática delitiva, o acervo probatório é sobremodo frágil no tangente à autoria do réu na perpetração delitiva, máxime diante da ausência de seguro reconhecimento pessoal dele em ambas as fases da persecução penal. Apenas o reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito aponta para a autoria do acusado, o qual, ‘embora se trate de meio legítimo de prova, sua utilização para fins de condenação do réu exige que seja confortado com outros elementos produzidos em juízo com observância do contraditório. Nesse sentido, aliás, a atual posição do STF, decidindo que “a utilização do reconhecimento fotográfico na condenação

pressupõe existirem outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea a decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova". (AVENA, Norberto, Processo Penal - 13. ed. - Rio de Janeiro: Forense; Método 2021, p. 628).

A dúvida em torno da autoria delitiva poderia ser dirimida se eventuais traços fisionômicos mencionados pelo adolescente Michael ao ensejo do reconhecimento fotográfico tivessem sido suficientemente documentados desde o início da persecução penal. Em teoria, seria dado arrostá-los com a fisionomia do réu, mitigando o grau de subjetivismo de seu reconhecimento. A apresentação de um relato pormenorizado das características do suspeito, quando evocado espontaneamente da memória do reconhecedor, possibilita ao julgador valorar, com maior grau de segurança, os apontamentos feitos por aquele que reconhece. Não por outro motivo, o CPP alinha como primeiro ato do procedimento a apresentação de descrição da pessoa a ser reconhecida (art. 226, I, do CPP). São cautelas que têm por escopo garantir a credibilidade do próprio ato de reconhecimento, o qual, na espécie, é o único elemento capaz de vincular o imputado aos crimes que lhe são imputados, diante da ausência de prisão em flagrante e de outras testemunhas oculares do fato.

Isto é: há indícios do envolvimento do acusado, que brotam do reconhecimento fotográfico realizado pelo adolescente durante a fase pré-processual. Entrementes, nenhuma outra prova foi produzida, sob o pálio do contraditório. O réu não foi reconhecido pessoalmente em juízo por qualquer das testemunhas, não foi preso em flagrante, tampouco algum entorpecente foi encontrado na sua posse, e sequer houve investigação prévia e elucidativa a respeito. É irrelevante se ele fora apontado anteriormente como suposto operador do tráfico na região, pois, à míngua de qualquer investigação mais apurada, a sua vinculação à traficância não passa do plano da conjectura; o direito penal esquadrinha fatos para identificar os seus autores (direito penal do fato), não partindo de perfis pessoais para daí discriminar as possíveis condutas criminosas em que estes incorreriam.

Ainda que, por suposto, fosse possível estribar a condenação no pretenso reconhecimento fotográfico, estar-se-ia diante de elemento amealhado na fase de inquérito policial, que não pode arrimar, por si só, a responsabilização criminal, nos moldes do art. 155 do CPP. Como anotam EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER: Elementos informativos e elementos probatórios: Rigorosamente falando, o material produzido na fase de investigação não pode ser considerado prova. Ao menos, em princípio.

A fase de investigação, como se sabe, é destinada à formação do convencimento do órgão da acusação e não do magistrado. Na aludida fase, não há preocupação com o contraditório, até mesmo porque sequer se exerce a defesa do acusado. Não há ali, à evidência, ampla defesa. A partir de uma notícia criminis, avança-se para uma apuração sumária de seus elementos comprobatórios, sempre voltada para o convencimento do órgão responsável pelo juízo acusatório. Esse, o juízo acusatório, pode ser positivo, em que há o oferecimento da denúncia ou queixa, ou negativo, hipótese em que se requer o arquivamento da investigação, quaisquer que sejam os seus fundamentos.

Apenas o material produzido em Juízo é que, a rigor, constituiria prova, abrindo-se necessariamente ao contraditório e à ampla defesa, com efetiva participação da defesa. Em princípio, portanto, apenas a prova se prestaria ao convencimento judicial, não cumprindo essa missão os chamados elementos informativos da fase investigatória.

A nova redação do art. 155, trazida pela Lei nº 11.690/08, inova. E, para pior, a depender da extensão de sua aplicação.

Diz o texto: "não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação". O que significaria isso?

Em primeiro lugar, é de se atentar para o fato de que a expressão "exclusivamente" não constava do anteprojeto original que veio a se transformar na Lei nº 11.690/08.

A ideia inicial era afastar qualquer possibilidade de valoração de material probante produzido unicamente na fase de investigação, ressalvadas as provas cautelares que não pudessem ser repetidas no curso da instrução (interceptações telefônicas, perícias em que já perecido o objeto da prova etc.).

Com o acréscimo (do “exclusivamente”), levanta-se, mais uma vez, a questão acerca da possibilidade de formação de convencimento judicial com base em elementos informativos produzidos na investigação.

É de se ver, então, que a inexistência de contraditório e de ampla defesa na fase de investigação preliminar, em princípio, impede a valoração judicial de tais elementos (informativos). Como regra, é claro, já que existem provas, ressalvadas inclusive na citada Lei nº 11.690/08, cuja natureza intrínseca não permite a sua reprodução em juízo. Não se pode, por exemplo, reproduzir a conversa captada em uma interceptação telefônica. Do mesmo modo, não se realiza prova pericial quando o objeto a ser periciado já não se encontra mais à disposição. E, nada obstante, tais meios de prova são aceitos aqui e, provavelmente, na maioria esmagadora dos ordenamentos jurídicos.

É que, em tais situações, o contraditório é diferido, ou seja, é adiado – da fase de investigação para a fase de instrução – permitindo-se que a defesa levante objeções técnicas, do ponto de vista jurídico ou tecnológico, àquele material realizado sem o controle judicial. Por certo que a qualidade das objeções é reduzida, na medida em que se cuida de questionamentos pos factum, sem o alcance das percepções imediatas, em tempo real.

Mas, diante da relevância e da gravidade dos danos causados pela infração penal – eis aqui outra das inúmeras justificativas para um Direito Penal de intervenção mínima –, o Direito se curva à necessidade de flexibilização na interpretação até mesmo de garantias constitucionais.

A expressão “exclusivamente”, portanto, não deve ser entendida como uma porta aberta para a livre valoração do material produzido na investigação, se presentes outras provas colhidas na instrução criminal. Não. Fosse assim, o convencimento judicial poderia ser construído com base essencialmente – e não exclusivamente! – em elementos informativos, bastando apenas a referência à existência de outras provas produzidas em Juízo.

Parece-nos que o tal “exclusivamente” apenas autorizaria um juízo de ponderação, de forma e principalmente de conteúdo, acerca das provas repetidas em Juízo, isto é, sobre a prova colhida na investigação e repetida em juízo. (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência – 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2020. pp. 410/411). (Negritei).

Em abono ao motivado, colho precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo em caso análogo ao dos autos:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Inexistência de reconhecimento pessoal do réu. Acusado que negou os fatos que lhe foram imputados e não foi preso em flagrante delito. Presentes meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Apelo defensivo provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. (Apelação Criminal nº 0004187-76.2017.8.26.0189, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Leme Garcia, j. 25.02.2021).

Logo, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, por falta de provas da autoria, é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para ABSOLVER o acusado GUILHERME DOS REIS BATISTA, já qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas por incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29 do Código Penal; art. 35 da Lei nº 11.343/2006; e art. 244-B, caput, do ECA, todos na forma do art. 69 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em razão do presente desfecho decisório, ORDENO a cessação das medidas cautelares fixadas na decisão de fls. 407/408 (art. 386, parágrafo único, II, do CPP).

Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe, expeça-se certidão de honorários em favor do nobre Patrono nomeado no valor máximo previsto na tabela vigente, e, após, arquivem-se os autos.

Porque órgão do Estado, o Ministério Público não paga custas, notadamente em procedimento processual penal.

P. R. I.

Itapecerica da Serra, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA